

1500452-66.2021.8.26.0626

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... provas de que a acusada participava do tráfico de drogas. Argumenta que as conversas telefônicas não são suficientes a tal comprovação. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da cláusula de 'tráfico privilegiado', em grau máxima, da detração e pelo direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Conquanto não apresentada sob título de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba-SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500452-66.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500452-66.2021.8.26.0626

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343897/2021 - 01º D.P.

CARAGUATATUBA, 22012207 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 1522/21/312 - 01º D.P.

CARAGUATATUBA, 2343897 - 01º D.P. CARAGUATATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO PIMENTA FERNANDES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de MARCELO PIMENTA FERNANDES e TATIANA JANINE LOMBARDI, já qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, II, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi apresentada nos seguintes termos:

"Consta no incluso inquérito policial que no dia 17 de dezembro de 2021, pela manhã, na Rua Maria Barreto da Silva, nº 56, Praia das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba, os denunciados, com unidade de ações e de comum acordo,

tinham em depósito, para fins de consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga, consistente em 255,20 gramas de maconha e 45 papelotes de cocaína (55,04 gramas), conforme o laudo de constatação de fls. 12/13, sendo certo que os acusados cometeram o crime prevalecendo-se da função pública do denunciado MARCELO PIMENTA FERNANDES. Tramita nesta Promotoria de Justiça o Procedimento de Investigação Criminal nº 94.0233.0000239/2021-5 em que se investiga a prática dos crimes previstos nos artigos 2º da lei 12.850/2013, artigo 317 do Código Penal, artigo 319-A do Código Penal e artigo 333 do Código Penal, em tese, praticados por diversas pessoas que atuam no tráfico de drogas nesta cidade de Caraguatatuba, incluindo servidores públicos, agentes penitenciários, dentro e fora do Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba. Após realização de diligências no Procedimento de Investigação Criminal, em que ficou cabalmente demonstrado que os acusados eram amantes e praticavam o crime de tráfico de drogas, foi requerida ao juízo medida cautelar de busca e apreensão. Deferida a medida, autos nº 1006805- 30.2021.8.26.0126, quando do cumprimento da busca e apreensão, “Operação Proditio”, foi encontrada a droga retro mencionada na casa do acusado MARCELO PIMENTA FERNANDES. Ambos os acusados estavam no local dos fatos e se valiam da função do denunciado MARCELO PIMENTA FERNANDES, agente penitenciário, para, de comum acordo, ingressarem com drogas dentro do Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba para o consumo dos detentos em troca do pagamento de valores. O acusado MARCELO PIMENTA FERNANDES confessou a prática do crime, informando ainda que já tinha ingressado com drogas no Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba por pelo menos outras 4 (quatro) vezes. Saliento que a acusada TATIANA JANINE LOMBARDI também foi alvo da “Operação Proditio”, mas não foi encontrada em sua casa justamente pelo fato de estar na residência do acusado MARCELO PIMENTA FERNANDES, o que demonstra que ela tinha total ciência das drogas que foram encontradas no local e também era responsável pela entrada do entorpecente no presídio.” (fls. 01-03).

As prisões em flagrante foram homologadas e convertidas em preventiva (fls. 73-78). Posteriormente, em razão de decisão do STJ, foi concedida prisão domiciliar à acusada Tatiana (fls. 494-497; 520-527).

A denúncia foi recebida na data de 31 de janeiro de 2022 (fls. 196-197).

Os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 255-262; 263-266).

O recebimento da denúncia foi ratificado, não se concedendo absolvição sumária e sendo determinada a realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 528-530).

O Ministério Público apresentou manifestação alegando descumprimento das condições do regime de prisão domiciliar, por parte da acusada (fl. 578). A defesa impugnou a narrativa, arguindo que se tratava de situação excepcional e que a decisão do STJ tem em vista também os filhos da ré (fls. 584-585; 586).

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas e a inquirição dos acusados, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 (fls. 604-606 e mídia anexa).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais (fls. 613-648), pela procedência da demanda. Argumentou que as provas dos autos são robustas e pesam em desfavor dos acusados, sustentando, em específico, que as conversas telefônicas entre os acusados evidencia a prática do tráfico de drogas por parte de ambos. A respeito da dosimetria, sustentou que a pena de ambos os acusados deve ser exasperada na primeira fase, elencando os fundamentos que entende atraem o aumento, e na terceira fase, nos termos do art. 40, II, da Lei de Drogas. Argumentou que indevida a aplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e devida a imposição de regime inicial fechado.

A Defesa de Marcelo apresentou alegações finais (fls. 650-660) sustentando, inicialmente, ofensa ao contraditório, em razão da tomada de depoimento de testemunhas sigilosas. Arguiu que inexistem provas suficientes à condenação. Neste contexto, alegou que as conversas telefônicas não tem o condão de comprovar qualquer ilícito; a confissão extrajudicial é falsa, sendo verdadeira a versão

apresentada em juízo; e inexistiram provas suficientes para comprovar que o acusado estaria inserido em esquema de tráfico de drogas. Alegou, ainda, que o acusado seria somente usuário de drogas, conforme também teria sido afirmado pela testemunha Giovana, vizinha do réu. Pugnou pela desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e inaplicabilidade do art. 40, II, do mesmo diploma legal. A Defesa de Tatiana apresentou alegações finais (fls. 664-668) alegando, em síntese, que inexistia qualquer prova em desfavor da acusada. Sustenta que Marcelo seria proprietário da droga e que não há provas de que a acusada participava do tráfico de drogas. Argumenta que as conversas telefônicas não são suficientes a tal comprovação. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da cláusula de 'tráfico privilegiado', em grau máxima, da detração e pelo direito de recorrer em liberdade. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Conquanto não apresentada sob título de preliminar, a defesa do acusado Marcelo apresenta teses de violação ao contraditório e ao devido processo legal, em relação à oitiva de testemunhas protegidas.

Nesse sentido, a despeito da nomenclatura, devida a análise das teses em sede preliminar, na medida em que eventual nulidade implicaria invalidade das provas. No ponto, a defesa de Marcelo alega, em síntese, que a oitiva das "testemunhas 1, 2 e 3", ouvidas nos autos 1006805-30.2021.8.26.0126, e anexadas nestes autos violaria o contraditório na medida em que os depoimentos ocorreram em caráter sigiloso, em fase investigatória e sem esclarecer a forma do procedimento. Sem razão, entretanto.

A uma, porque a oitiva de testemunha cujos dados não são revelados é procedimento disciplinado pela legislação pátria, nos termos da Lei nº 9.087/99, a qual no art. 7º, IV, expressamente prevê a necessidade de preservação dos dados pessoais dos depoentes.

Nesse sentido, o e. STJ tem entendimento absolutamente consolidado no sentido de que a oitiva de testemunhas protegidas - sem que se revelem seus dados - não viola o contraditório ou o devido processo legal. Por todos, veja-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES. PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO DA TESTEMUNHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 7º, inciso IV da Lei nº 9.807/99, é assegurada às pessoas protegidas, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, a preservação da sua identidade, imagem e dados pessoais. 2. Hipótese na qual foi colhido depoimento na fase inquisitorial, sendo o nome da testemunha preservado diante da gravidade concreta do caso, em que se apura suposto homicídio cometido em contexto de rivalidade entre facções criminosas notoriamente perigosas - Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. 3. O caso justifica uma ponderação de valores, especialmente por ser compreensível o temor da testemunha, assim como verossímil o perigo à sua vida e integridade ao fornecer informações referentes ao caso. Aliás, consta dos depoimentos de outra testemunha que "a motivação do crime foi pelo fato de que Leandro deu "fita" para o pessoal da Baixa, avisando onde Milton Neto estava". Ou seja, a vítima teria sido executada exatamente por fornecer informações que desagradaram o grupo criminoso. 4. Ademais, embora tenha sido assegurada à testemunha a supressão dos seus dados, entre eles seu nome, na fase do inquérito policial, "deverá ser assegurado à defesa o acesso aos dados sigilosos da testemunha protegida por ocasião da audiência de instrução e julgamento", inclusive como meio para que o patrono do paciente realize perguntas, não havendo que se falar em violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 5. A tese de ausência de comprovação dos trâmites legais para a inclusão da testemunha no programa de proteção não foi enfrentada pelo acórdão atacado, tampouco objeto de embargos de declaração, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 6. Não obstante, verifica-se que o procedimento adotado nos autos encontra-se amparado pelo Código de Normas Judiciais daquele Estado, que autoriza o juiz, o

representante do Ministério Público e o delegado de polícia, visando preservar o nome, endereço e demais dados de qualificação da vítima ou testemunhas sob coação ou grave ameaça, a anotarem tais dados em autos apartados, a serem depositados em pasta sigilosa própria. 7. Agravo desprovido." (AgRg no RHC n. 152.215/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Vale dizer: havendo expressa previsão legal para o procedimento, a prova somente poderia ser rejeitada na hipótese do dispositivo que ampara a medida estar em desconformidade com a ordem constitucional. No entanto, tal situação não ocorre, dado que, conforme destacado no julgado acima, são razoáveis os motivos que conduziram a norma em comento e, havendo posterior possibilidade de contraditório, tal como ocorrido nos autos, não há de se falar em violação ao devido processo legal.

Ademais, embora os depoimentos não tenham sido tomados nestes autos, nota-se que a medida de preservação dos dados foi justificada de maneira suficiente, dado que, conforme a própria defesa reconhece, os depoentes ouvidos na fase de inquérito dos autos 1006805-30.2021.8.26.0126 seriam detentos encarcerados na unidade prisional em que o acusado laborava.

Ainda no ponto, note-se que, eventual nulidade dos depoimentos – o que, como visto, inexistente – teria, em tese, ocorrido em fase de inquérito de outro procedimento, não prejudicando, pois, a possibilidade de exame do mérito da pretensão punitiva destes autos.

Neste contexto, o que se verifica é que inexistente qualquer tese de nulidade ou invalidade suficiente a impedir o julgamento do mérito, sobretudo, porque a instrução deste feito foi devidamente realizada, sendo todas as informações processuais submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. *Justificação e Crítica – perspectivas de uma teoria crítica da política*. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. *Sobre a Violência*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência dos fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. *Ônus da prova no processo penal*. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório.

Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática do delito imputado à ré.

3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 11; 24), auto de exibição (fls. 16-17), auto de constatação preliminar (fls. 22-23), boletim de ocorrência (fls. 12-14), fotos (fls. 06-10), laudos periciais (fls. 569-571; 572-574), conversas por mensagens telefônicas (fls. 158-162; 185) bem como pela prova oral produzida em juízo.

4. A autoria está também demonstrada, pesando em desfavor dos acusados, sobretudo pelos depoimentos apresentados em juízo e em fase policial.

A testemunha Clayton (policial militar) narrou que participou de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado. Disse que ao indagar a respeito da existência de droga e apresentar o mandado, o acusado confirmou que tinha em casa as drogas apreendidas. Afirmou também que havia outra pessoa na casa, que foi identificada como a acusada Tatiana. Relatou que o acusado confessou a prática de delitos, dizendo que ingressava com drogas no CDP. Disse, ainda, que durante a abordagem foi filmado o acusado confessando tal situação. A acusada Tatiana disse não ter ciência a respeito da droga. Afirmou que a droga estava a vista no local, em cima de uma mesinha, e acredita que não seria possível que a acusada não tivesse ciência a respeito das drogas. Especificou que a mesinha, em que as drogas foram localizadas, estava em frente a um colchão, que também estava na sala. Disse que as drogas estavam em uma sacola transparente de mercado – assim como aqueles que se colocam verduras –, em cima desta mesinha. Afirmou não ter visto drogas desembaladas, como indicando que seriam para consumo. Disse não saber indicar se o acusado apresentava sinais de uso de droga.

A testemunha Rodrigo (policial militar) disse que participou da diligência de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado Marcelo. Afirmou que foi possibilitada a entrada, sem maiores complicações. Descreveu a casa como um local de poucos móveis e bastante modesta. Disse que na residência também estava a acusada Tatiana. Na residência foram encontradas drogas, que estavam em uma sacola plástica 'cor invisível'. Relatou que o acusado não demonstrou nervosismo ou espanto, confessando que adentrava com entorpecentes do CDP, afirmando que recebia R\$ 1.000,00 (mil reais) por cada empreitada. Afirmou que foi feita uma gravação do acusado confessando. Disse que as drogas estavam visíveis, de forma que não teria como não vê-las. Afirmou que as drogas foram o segundo objeto que visualizou. Disse que estavam em uma sacola, que até mesmo estava aberta, embora as porções individuais estivessem embaladas. Não recorda se havia algum papel cobrindo as drogas. Afirmou que as drogas foram encontradas em uma mesa, na sala. Não recorda se todas as drogas estavam na sacola ou se outras também foram encontradas. Disse que sua função na operação era dar segurança aos policiais. Esclareceu que acompanhou a apreensão da droga, embora não saiba dizer se, além daquela porção relatada, alguma outra foi encontrada. Disse que embora foram encontradas algumas anotações, não sabendo precisar se tinham relevância para fins de traficância.

A testemunha Alan Carlos (diretor-geral do CDP de Caraguatatuba) narrou, em síntese, que após algumas apreensões de ilícitos no CDP, sugeriram informações de que existiria a participação de servidores envolvidos na entrada de objetos no centro de detenção, sendo possível notar que existia sempre uma proximidade do acusado Marcelo com a situação. Ainda, que era possível notar que o acusado Marcelo estava sempre em conversa com 'presos lideranças'. Afirmou algumas pessoas aceitaram relatar formalmente. Em sequência, várias pessoas passaram informações dizendo que Marcelo ingressava com drogas no centro de detenção. Relatou que estava no momento em que Marcelo confessou que realmente introduzia drogas no presídio.

Posteriormente, o preso Edson relatou que o acusado Marcelo lhe ameaçava para que fizesse a distribuição de drogas no CDP, entorpecentes que o acusado Marcelo introduzia no presídio. Relatou ainda que existiam informações anônimas, de presos e visitantes, de que a acusada Tatiana também atuava na introdução de drogas no presídio. Afirmou que as informações é de que Marcelo e Tatiana teriam um relacionamento amoroso e que atuavam juntos na compra e introdução de drogas no CDP. Afirmou que na data da prisão a pessoa de Jean (marido da acusada Tatiana) não estava mais custodiado no CDP de Caraguatatuba, acreditando que estava em Tremembé. Disse que é possível que uma pessoa pode entrar em dois presídios distintos, caso tenha autorização, não sabendo se este seria o caso da acusada Tatiana. Disse não saber se ocupava a posição de diretor do CDP de Caraguatatuba quando Tatiana visitava seu marido, pois não sabe a data em que isto ocorreria, mas acredita que sim, pois é diretor desde agosto de 2018. Disse que não lembrar de algum caso em que Tatiana teria sido apreendida tentando entrar com entorpecentes no local.

Relatou que no turno em que Marcelo trabalhava aproximadamente 18 pessoas, de um total de 150 servidores que existem no CDP. Disse que é difícil estimar ao certo com quantas pessoas Marcelo trabalhava, dado que isto depende da escala e de variações ocorridas no curso do próprio labor. Relatou a respeito de um reconhecimento que teria sido realizado perante o Ministério Público. Disse que no CDP há um scanner, mas que o equipamento não é imune de falhas.

A testemunha Giovana (vizinha do acusado Marcelo) disse, em síntese, que Marcelo seria um 'bom vizinho' e uma pessoa boa. Relatou que sentia cheiro de maconha, vindo da casa de Marcelo. Disse que Marcelo nunca se queixou para si a respeito de stress com o trabalho. Afirmou que não conhece Tatiana.

A informante Marcela (amiga íntima de Tatiana) relatou, em síntese, que conhece Tatiana há 04 anos e nunca soube de envolvimento da acusada com tráfico de drogas. Disse que o marido da acusada está preso e que ela ia visitar ele. Relatou não saber de caso extraconjugal da acusada, relatando somente que por diversas viu ligações do acusado Marcelo à acusada Tatiana, mas não sabe de relacionamento amoroso entre eles.

A testemunha Nelson (inquilino de imóvel da acusada) apresentou um relato abonatório a respeito de Tatiana. Disse que a acusada trabalharia com aluguel de imóveis e depilação.

Em seu interrogatório, a acusada Tatiana disse que conheceu Marcelo em agosto de 2020, após seu marido ter encaminhado o contato do acusado para ela, pois teria 'tomado um gancho' na unidade. Em seguida, Marcelo teria mandado mensagens para a acusada e, passado um ano, iniciaram um caso extraconjugal. Após alguns encontros, o acusado lhe convidou para vir a sua casa em Caraguatatuba. No dia seguinte, por volta das 06h00, a casa do acusado foi objeto de busca e apreensão, momento em que notou a apreensão de drogas. Disse não morar em Caraguatatuba, não traficar ou usar drogas. Negou que fosse dona das drogas e que soubesse dos entorpecentes de Marcelo. Relatou que as drogas não estavam visíveis na casa do acusado. Disse ter ficado indignada com o fato de que Marcelo teria drogas em sua casa. Relatou que seu esposo quem passara seu número de celular a Marcelo, quem teria iniciado o contato, dizendo que ela teria 'pego um gancho' e seu esposo estaria pedindo um 'sedex' com bens. Narrou como teria sido inicialmente suas conversas com Marcelo. Negou que mensagens sobre compra e venda de bens, lidas pelo promotor, sejam suas. Disse nunca ter conversado sobre 'cágua' com Marcelo. Relatou que não vende drogas. Exibida a fl. 161 à acusada, negou que a conversa fosse sua. Disse não saber o que seria 'docinho no pavilhão'. Afirmou que há 04 anos mora em Taubaté e ao tempo dos fatos seu marido estava preso em Tremembé.

Em seu interrogatório, o acusado Marcelo disse que a droga, em sua residência, era somente sua e Tatiana não sabia dos bens. Afirmou que as drogas não se destinavam à traficância, porém algumas se destinavam ao seu uso próprio. Disse não recordar da conversa que teve com o promotor em momento anterior, pois havia utilizado drogas na noite anterior inteira. Afirmou que não fez uso de drogas na frente de Tatiana no dia anterior. Relatou que nunca entrou com drogas no CDP. Disse que Tatiana foi a sua casa, pois estavam tendo um caso, mas ela desconhecia a respeito das drogas. Narrou que no dia anterior a sua prisão fez uso de drogas e que sempre utilizou muita droga, fazendo uso de maconha e cocaína quase todo dia. Disse que fumava cerca de 10 cigarros de maconha por dia e que as drogas que tinha em sua residência utilizaria em menos de um mês, mas as armazenava uma vez que não gosta de 'ir à biqueira'. Relatou que não se recorda do que disse em seu depoimento em fase de inquérito, uma vez que utilizara entorpecentes na noite anterior.

5. Diante deste contexto, autoria e materialidade estão, de maneira geral, comprovadas, conforme passo expor adiante.

5.1. No ponto, ressalto, em primeiro lugar, que os policiais narram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa a acusada. Ao contrário, o que se observa é que os agentes públicos asseveraram com precisão o desdobramento do fato, imprimindo certeza e seriedade em sua narrativa.

Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o

testemunho dos policiais tem valor idêntico aos de outras pessoas que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

“3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).” (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)”.

5.2. Nesse cenário, observe-se que os relatos confirmaram a pretensão punitiva descrita na inicial acusatória. Isto porque a narrativa apresentada pelas testemunhas é robusta, harmônica e verossímil, encontrando respaldo nas demais provas dos autos, em especial os laudos periciais e auto de apreensão das drogas. Ademais, o próprio acusado não negou estar com as drogas em depósito, razão pela qual materialidade e autoria são inequívocas, sendo a controvérsia destinada em especial à análise da tipicidade.

5.3. Neste contexto, observe-se que é incontroverso que o acusado Marcelo estava armazenando os entorpecentes em sua casa.

Todas as pessoas ouvidas, inclusive, o próprio acusado confirmam este fato.

No ponto, a controvérsia centra-se, somente, a respeito da tipicidade da conduta. O Ministério Público sustenta que os entorpecentes destinavam-se a traficância, enquanto o acusado alega que seria para uso próprio.

Este dissenso, no entanto, é relegado à fase posterior da análise da suposta prática delitiva. Ao momento, é inequívoco que materialidade e autoria pesam em desfavor do acusado, uma vez que, conforme diversos relatos e documentos, a droga foi apreendida sendo armazenada em sua residência.

5.4. Igualmente, materialidade e autoria pesam em desfavor da acusada Tatiana.

Os diálogos transcritos nos autos, frutos de interceptação telefônica, evidenciam que a acusada Tatiana não somente tinha consciência a respeito do tráfico de entorpecentes, como também, juntamente com Marcelo, atuava na comercialização das drogas.

Nesse sentido, transcrevem-se trechos, bastante elucidativos, das conversas entre os acusados:

TATIANA - Não sei se eu vou descer essa semana. Eu nem sei mais se eu vou pegar mais aqueles BARATO, sabe porquê, Má (Marcelo). Meu, o cara, enrolado, tá parecendo um nóia, me fazendo...

MARCELO - Ele tá viajando, ele tá viajando.

TATIANA - Eu vou falar pra ele, eu vou falar brother cê tá parecendo um nóia, me dando gasto, com droguinha. Aí hoje ele me pede (inaudível) no email.

MARCELO - Aí você tem que falar pra ele, meu se decide, porque você fala que não é pra mandar, agora você fala que é pra mandar, não tô entendendo porra nenhuma.

TATIANA - Aí, aí tipo eu vou lá e faço dívida com a Lilian, beleza, vai ficar no meu nome, né? Porque ele tá preso e a dívida vai ficar no meu nome... .. essa pessoa nunca me ligou, essa pessoa que ele fala que é a PONTE. Então, assim, eu não

sei, eu não tô sentindo confiança. Como que eu vou pegar um BARATO e... ... tipo, eu tenho que pagar, entendeu. O cara tá me dando despesa, ou ele decide, ou eu invisto em mercadoria ou ele fica fumando droga. É isso Má. Essa que é a real. Aí depois eu vou ver, arrumo lá os bagulho, Pra quê? Pra ele ficar distribuindo docinho no pavilhão.

MARCELO - É estranho, né?

TATIANA - Cê entende?

MARCELO - Entendo, bem estranho.

TATIANA - E dinheiro picado eu não vejo a cor...

... e aí? Cadê a PONTE do caralho que nunca me liga, meu? Cê tá me entendendo? Se é pra mim pegar o BARATO, e a minha visita é no sábado, e ela vai atracar no domingo, cadê essa pessoa, Marcelo? Quer dizer, vai ficar só pra daqui quinze dias, aí eu vou ficar com uma dívida daqui a quinze dias. Resumindo eu não vou pegar nada, Má. Não vou pegar nada no meu nome.

MARCELO - É mesmo.

TATIANA - Cê entendeu onde eu quero chegar?

MARCELO - Eu entendi.

TATIANA - Aí eu quero sair, pego aí na quinta-feira, aí o BARATO, inaudível, legal. Ela me solta, só ligar pra ela, tá na mão, duzentos, quinhentos, duzentos ou cem. Entendeu?

MARCELO - Entendi.

TATIANA - Só que assim, aí eu vou visitar ele Sábado. Cadê essa pessoa? Aí de repente eu vou no sábado, o cara vem com uma continha de quatrocentos. Cê tá me entendendo, Má?

MARCELO - Tá complicado, tá estranho.

TATIANA - Tá complicado, a gente não tá entrando num entendimento. Eu e ele, a gente não tá entrando num entendimento. Ele fala, vai lá, pega o BARATO, que eu vou te passar a PONTE, já era. Investe mesmo, que eu faço virar um dinheiro aqui, mas não... tá estranho, Má.

MARCELO - Tá esquisito, né?

TATIANA - Tá esquisito.

MARCELO - Também acho.

TATIANA - Cê não acha que eu tô certa? Aí pra quê que eu vou gastar gasolina aí em Ubatuba, pra quê? Pra subir com o BARATO, e aí? Vai ficar dentro da minha casa. Beleza. Eu guardo isso aí dentro da minha casa. Mais e aí, Má? Entendeu? Cadê a mina a PONTE, já era pra... ... pra mim é assim, PONTE vive disso, cê concorda?

MARCELO - É eu também acho, meu.

TATIANA - PONTE que é PONTE, vive disso, entendeu? Já taria me ligando. "E aí Fulana? Já tá mão o BAGULHO? Tá ? Num tá? Que dia que vai rolar? " Cadê, meu? Cadê? A visita dele é sábado aí agora só da outra quinzena. Aí eu vou pegar esse BARATO com a Lilian. A Lilian que falou pra mim que se receber tem que pagar. E, aí? O BAGULHO tem que virar, girar, Má. ... pelo que eu entendi ele não tem contato nenhum, quem tem o contato sou eu, que é a mina, ele não tem contato nenhum, eu que tenho o contato, ca mina de Ubatuba, entendeu? ... essa PARADA aí, vem de Santos. ele não tem contato nenhum, e cadê as PONTE? Nem a PONTE... precisa pra arrumar, ele fala não tem como eu mandar a ponte entrar em contato com você, se você não tem mercadoria. Eu falei: como não? A PONTE vais gastar o quê? Uma ligação?, Uma mensagem de WhatsApp? ... não sei quem é essa pessoa que ele arrumou, que vai entrar com o BAGULHO, se ela vive disso ela tem que ta interessada, né?

MARCELO - É, então. Lógico. Tá estranho.

TATIANA - De verdade, já era pra essa pessoa ter me ligado, tipo amanhã, descia, na quarta-feira já entregava pra ela e tchau. Entendeu? Pra entrar no sábado e no domingo.

[00:45:44:704]" (fl. 160-162 - destacou-se).

Ainda mais:

"[01:19:41:385]

TATIANA: Aí ele falou assim, aí parece que chegou um salve do Comando, e parece que

vão breçar os "K4", se tá sabendo né?

MARCELO: É, não...dizem que chegou um salve, mas não do "K4"...é o que eu tô sabendo mermo, que vão breçar alguma coisa...

TATIANA: É o K4...

MARCELO: É...

TATIANA: Aí ele falou: " a tomara que até breque, por que eu paro...". Eu falei cara...você parece que... teve uns caras...é o seguinte.. chamei ele de nóia mesmo, eu falei pra ele, conversei o Bruno, e o Bruno falou que você fuma esse K4, e a brisa é muito rápida, então ela dá abstinência no cara...

[01:20:39:655]

2° intervalo

[01:21:22:082]

MARCELO: Breçar né...

TATIANA: Más, como que vai breçar, se dá dinheiro, o bagulho?

MARCELO: Dá, mas é mais caro tb, deve ser por isso...

TATIANA: Como assim muito caro?

MARCELO: Uns 4 pau o milheiro...

TATIANA: É isso mesmo, ele falou, ele falou pra mim, me arruma, ele falou, arruma pra mim 3 conto, que eu faço 6 aqui, e te dô, te ajudo...

[01:21:44:211]" (fl. 185)

Evidentemente, as transcrições indicam à prática do tráfico de drogas.

A despeito do cuidado dos interlocutores em evitar expressões literais, valendo-se, na maioria, das vezes de gírias ou outros padrões linguísticos que não apontam ao uso comum dos vocábulos, é absolutamente evidente que a conversa tem em vista a comercialização de entorpecentes.

Nesse sentido, é possível até mesmo reparar que, por lapsos, em alguns trechos os interlocutores transparecem a realidade linguística dos objetos da conversa. Por exemplo, quando Tatiana afirma que "Bruno falou que você fuma esse K4, e a brisa é muito rápida, então ela dá abstinência no cara" (fl. 185) ou, também, quando diz que "Como que eu vou pegar um BARATO e... .. tipo, eu tenho que pagar, entendeu. O cara tá me dando despesa, ou ele decide, ou eu invisto em mercadoria ou ele fica fumando droga É isso Má. Essa que é a real. Aí depois eu vou ver, arrumo lá os bagulho, Pra quê? Pra ele ficar distribuindo docinho no pavilhão." (fl. 161).

É evidente que dentro do contexto (ou, melhor, do 'jogo de linguagem'), diversas das expressões são empregadas como sinônimos de entorpecentes. Não por outra razão, a pessoa de Bruno teria dito que "você fuma esse K4, e a brisa é muito rápida, então ela dá abstinência no cara".

Aliás, é importante notar que além do cuidado linguístico os acusados também, aparentemente, evitavam se comunicar via telefone. Nesse sentido, é o diálogo entre Marcelo e Tatiana à fl. 160:

"MARCELO - Ah! Só que cê tá na ligação de linha, né? Cuidado com as coisas que você fala aí, viu?

TATIANA - Ah!, é. Esqueci. Rsr rsrs. Tá, parei, parei, parei.... Ainda bem que você me lembrou. Verdade." (fl. 160).

Diante de todo este contexto, é inequívoca a autoria da acusada Tatiana face as acusação que lhe são impostas. Não somente sua vinculação com os fatos está comprovada (autoria), bem como os elementos centrais do dolo direito (consciência e vontade) estão demonstrados.

Vale dizer: as partes muito debateram se a acusada saberia ou não da existência de drogas na casa de Marcelo no momento da apreensão. A toda evidencia os depoimentos demonstram que a ré, sim, saberia das drogas. Afinal, conforme todos os depoimentos a sacola contendo as drogas estava à mostra, em uma mesinha na sala, sendo esta sacola transparente (tal qual sacos de mercado).

No entanto, tal situação - embora esteja demonstrada - é de somenos importância para fins de delimitação da autoria de Tatiana nos delitos que lhe são imputados, dado que as transcrições acima evidenciam, de maneira inequívoca, que a acusada participava da mercancia de drogas.

Dessa maneira, entendo que estão comprovadas autoria e materialidade da conduta descrita na exordial.

6. Por esta razão, passa à análise do tipo penal.

6.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: "Art.33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". (grifo nosso).

In casu, a conduta da agente se ajusta aos verbos descritos no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que as provas dos autos demonstram, de maneira segura, que o acusado Marcelo tinha em sua residência ("tinham em depósito") as drogas apreendidas nos autos, o que ocorria com absoluta colaboração funcional da acusada Tatiana, que atuava, juntamente com o réu Marcelo, na mercancia de drogas. (conforme acima exposto)

Ademais, diante do cenário probatório, torna-se inequívoca a existência do tipo penal do art. 33, da Lei de Drogas, haja vista objetos apreendidos durante a apreensão do acusado, os quais evidenciam, para além de dúvida razoável, a existência de tráfico de drogas.

É que, além da significativa quantidade de drogas apreendida (255,20 gramas de maconha e 55,04 gramas de cocaína), os diálogos acima transcritos evidenciam, para além de qualquer dúvida razoável, que os entorpecentes se destinavam a mercancia, na unidade prisional em que o acusado Marcelo trabalhava e que o marido da acusada Tatiana esteve custodiado.

6.2. Diante deste cenário probatório, inviável a pretensão de desclassificação das condutas para o art. 28, da Lei de Drogas.

A uma porque a versão se encontra desamparada de qualquer substrato probatório.

Ademais, o simples fato de uma pessoa usar drogas, não impede que também pratique o delito do art. 33, da Lei de Tóxicos. A duas que a própria versão de uso é, em si, contraditória e inverossímil. No ponto, veja-se a incongruência entre as alegações de Marcelo, afirmando que teria passado a noite toda utilizando drogas, e Tatiana, que diz ter ficado em companhia de Marcelo por toda a noite e não ter visto drogas em momento algum. E, ainda, a três, que, conforme acima exposto, as provas dos autos indicam expressamente a existência de mercancia/tráfico de drogas envolvendo os acusados - nesse sentido, mais uma vez: os depoimentos prestados em fase de investigação e perante o juízo e as interceptações telefônicas constantes dos autos e acima transcritas.

6.3. Ainda a respeito da tipicidade, devida a aplicação do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Isto porque inequívoco que o tráfico de drogas se destinava ao CDP, em que o acusado Marcelo trabalhava. Nesse sentido são os depoimentos prestados em fase de investigação e perante o juízo. São também as transcrições de mensagens acima já expostas, em que, inclusive, se menciona a distribuição de drogas no 'pavilhão'. Ademais, embora as drogas não tenham sido apreendidas no CDP, é necessário observar que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, basta que os entorpecentes visem atingir local descrito no art. 40, III, da Lei de Tóxicos, sendo dispensável a efetiva apreensão do ambiente.

Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que para imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.

11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer

frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC n. 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015), ainda mais in casu, onde o tráfico de drogas era realizado por um detento dentro do próprio estabelecimento prisional.” (AgRg no HC n. 547.484/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020). “3. O inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06 não faz a exigência de que as drogas, objeto do crime, efetivamente passem por dentro dos locais que se busca dar maior proteção, mas apenas que cometimento dos crimes tenha ocorrido em seu interior.” (HC n. 440.888/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019).

6.4. Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, entendo incabível.

Isto porque, a despeito da primariedade dos agentes, está demonstrado que ambos se dedicavam, de maneira reiterada, à prática do delito de tráfico de drogas e integram organização criminosa.

Nesse sentido, as mensagens entre os acusados. Nos diálogos é possível perceber a existência de uma organização para o cometimento reiterado do delito de mercancia de entorpecentes. Tanto é assim que a acusada Tatiana fala em 'investimentos' e na pretensão de melhorar o 'desempenho' de seus 'pontes'. Ademais, as mensagens também evidenciam que a atividade delitiva estava ocorrendo há tempo significativo, sendo, inclusive, possível constatar pequenas fricções entre aqueles que atuavam na cadeia ilícita.

Ainda mais sintomático da impossibilidade de aplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 são as reiteradas menções dos acusados ao 'Comando', em inequívoca alusão a organização criminosa. Nesse sentido, as mensagens de Tatiana às fls. 170; 185. Diante deste contexto, indevida a aplicação do 'tráfico privilegiado'.

7. A respeito dos demais elementos dos injustos penais, observa-se que os acusados são imputáveis, têm a consciência da ilicitude de suas ações, lhes era exigível conduta diversa e não agiam amparado por causa excludente de ilicitude, devendo, então, responder pelas ações praticadas, dado que todos os elementos da estrutura analítica dos delitos estão presentes.

8. Ante o exposto, restou claramente demonstrado que a acusada MARCELO PIMENTA FERNANDES e TATIANA JANINE LOMBARDI, realizou a conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo penal indicado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

9. Passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06 apresenta pena abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

9.1. Na análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, não foi possível valorar a conduta social e o comportamento da vítima, a personalidade da agente, em razão da ausência de elementos informativos a respeito de tais vetores. Ainda, os motivos e consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

Os acusados são primários (fls. 552.553; 554-555).

A culpabilidade é neutra em relação à acusada Tatiana. Porém, pesa muito em desfavor do acusado Marcelo. Isto porque o acusado era agente penitenciário do local que as drogas se destinavam. Isto é, tinha o múnus o público de cumprir com seu dever funcional na forma do art. 37, da CF, e, justamente, prevenir a ocorrência de delitos. No entanto, o acusado não somente deixou de desempenhar sua função; ao contrário, praticou justamente aquilo que deveria reprimir. Veja-se, portanto, o grau de censura que deve ser imposto ao comportamento: um agente público, responsável por manter a segurança e ordem um local (no caso, um estabelecimento prisional) praticou condutas que, justamente, violavam aquilo que deveria ter prevenido. É importante dizer: a situação seria severa fosse cometida por qualquer servidor público. No entanto, é ainda mais, porque praticada justamente por aquele que deveria reprimir a situação. Nesse sentido, há muito pacificado pelo e. STJ, a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade (por

todos, veja-se: AgRg no HC n. 729.305/PR, relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No ponto, destaque-se que por ser circunstância de natureza subjetiva, impossível a comunicabilidade, nos termos do art. 29, do CP.

As circunstâncias do delito pesam em desfavor dos acusados. Isto porque as informações processuais – com destaque aos depoimentos e interceptações já citados – evidenciam que o caso não trata de uma 'singela' mercancia de entorpecentes.

Antes, o delito em apuração tem em vista um esquema, com sofisticação, para entrada e mercancia de drogas em estabelecimento prisional. Veja-se: a circunstância transcende, em muito, o que ordinário ao tipo. Não somente em razão do local a que as drogas se destinavam (o que será avaliado a título de qualificadora, conforme exposto acima), mas pela organização e complexidade do esquema de cometimento do crime.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei 11.343/06, estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas.

In casu, a quantidade de drogas, não deve ser sopesada nessa etapa. Mesmo que a quantidade não seja desprezível, encontra-se consonância com os padrões ordinários verificados na prática. Igualmente, inexistente razão à valoração negativa da natureza do entorpecente. Em contrapartida, a natureza da droga deve ser analisada negativamente, uma vez que uma das substâncias em análise (cocaína) é capaz de gerar gravíssimos danos à saúde e implicar em forte dependência química, conforme consenso na comunidade científica, transcendendo, pois, ao inerente da espécie delitiva tal qual ocorre com tóxicos que, ainda que proibidos, são de natureza mais branda (ex.: lança perfume, maconha, haxixe, dentre outros).

9.1.1. Veja-se, portanto, que são 03 circunstâncias judiciais que pesam em desfavor do acusado Marcelo (culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza da droga) e duas que pesam contrariamente a acusada Tatiana (circunstâncias do crime e natureza da droga).

9.1.2. A questão é, então, definir o quantum de aumento a ser aplicado nesta primeira fase. É certo que o art. 59, do CP, ou qualquer outra norma, define de maneira específica como deve ser dosado o aumento.

Nesse sentido, a jurisprudência construiu dois critérios distintos e que continuam a dividir entendimentos, sem que nenhum deles tenha alcançado hegemonia ou pacificado os dissídios sobre o tema. Ambos os critérios entendem que o aumento deve ser de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância. No caso dos delitos de lei de drogas, sendo 10 as circunstâncias avaliadas, o entendimento é de que o padrão de aumento deve ser de 1/10 (um décimo).

No entanto, há controvérsia a respeito de qual deve ser a 'base de cálculo' para esta aplicação do aumento: se o mínimo da pena abstratamente prevista ou se o intervalo da pena.

Ambas as teses são recepcionadas pelas Cortes Superiores, embora em sua maioria o entendimento seja de que a fração de aumento deve incidir sobre o intervalo entre as penas máximas e mínimas abstratamente cominadas.

"2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ." (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

"6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador."

(STJ AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

9.1.3. In casu, considerando que em razão do art. 42, da Lei 11.343/06, são 10 (dez) as circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase, o aumento deve, à luz da jurisprudência do e. STJ, ser no patamar de 1/10 (um décimo) do intervalo entre a pena máxima e mínima, para cada uma das circunstâncias negativas. Ao exposto, fixo a pena-base: (i) do acusado MARCELO em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa; e (ii) da acusada TATIANA em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

9.2. Passo à segunda fase da dosimetria. Neste momento, analisam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes.

9.2.1. Em relação à acusada Tatiana não incidem agravantes ou atenuantes.

9.2.2. Em relação ao acusado Marcelo presente a agravante do art. 61, II, g, do CP, na medida que o réu se utilizou de seu cargo para cometer o delito, uma vez que possuía acesso privilegiado ao CDP, em razão de seu cargo de agente penitenciário. No ponto, é imprescindível realizar um distinguish para que não recair no equívoco de imaginar existir bis in idem entre a presente valoração (crime cometido com violação do dever inerente ao cargo) e a análise da reprovabilidade na etapa anterior. Isto porque os ângulos de avaliação e os motivos que conduzem as conclusões são distintos em cada um dos exames.

Na análise da culpabilidade se tinha em vista a reprovabilidade da situação e o grau de censura que recaia sobre o comportamento do agente. Isto é, havia uma análise da culpabilidade subjetiva (ou seja, do juízo particular de reprovabilidade que recaia sobre o comportamento). Por esta razão, considerando que o acusado era servidor público – e independente de seu cargo, em específico – sua conduta era mais reprovável/censurável do que de outrem, que alheio à administração pública. A este momento a situação é diversa. Não se analisa o aspecto subjetivo. Agora está em exame a circunstância objetiva do crime. E está é inequívoca no sentido de que o acusado Marcelo violou dever de ser cargo e, inclusive, valeu-se dele para o cometimento do crime.

Portanto, plenamente possível a aplicação do art. 61, II, g, do CP, sem que tal configure bis in idem.

Inexistem atenuantes em favor do acusado Marcelo.

9.2.3. Desta forma, mantenho inalterada a pena de acusada Tatiana, ao passo que exaspero em 1/6 (um sexto) a reprimenda do acusado Marcelo.

Logo, fixo as penas intermediárias: (i) do acusado MARCELO em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa; e (ii) da acusada TATIANA em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

9.3. Na terceira fase da dosimetria analisam-se as causas de aumento e diminuição. In casu, presente a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.43/06, conforme acima exposto.

A respeito do